SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1082334 - SP(2026/0103559-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	GILSENIR SOARES CLEMENTINO (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Cuida-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de GILSENIR SOARES CLEMENTINO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502530-58.2025.8.26.0540.

Em 16 de setembro de 2025, o paciente foi preso em flagrante na posse de um saco plástico contendo cocaína (152g) e mais 30 *eppendorfs* com a mesma substância (1103g). A prisão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas e informações obtidas pelo serviço de inteligência da Polícia Civil.

Encerrada a instrução, o juízo da 2ª Vara Criminal de Mauá julgou procedente as acusações e condenou o paciente a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa. A sentença foi parcialmente reformada apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ, fls. 83-98).

Por meio deste *habeas corpus*, a defesa, inicialmente, questiona a validade das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem prévias e fundadas razões que a justificasse.

Em caráter subsidiário, pretende a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que não foram apresentados elementos fáticos e probatórios juridicamente idôneos para sustentar o afastamento do benefício.

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

Diante do exposto requer a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, a redução da pena, com abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. **Decido.**

O presente *habeas corpus* não merece ser conhecido a adequação da via eleita.

De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no *habeas corpus* é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, como é o caso, é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, na medida em que o referido dispositivo faz menção expressa a *causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais*.

Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 27/5/2015.

Cito, ainda, os seguintes precedentes:

> PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. *HABEAS CORPUS* NÃO CONHECIDO.
> I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de *habeas corpus* substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do *writ* substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel.

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

> Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
> II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de *habeas corpus* substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
> [...] *Habeas corpus* não conhecido. (HC 320.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 27/5/2015).

> *HABEAS CORPUS*. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
> 1. O *habeas corpus* tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o *writ* amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de *habeas corpus* por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo *habeas corpus* em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento de recurso ordinário contra a denegação do *habeas corpus* pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo *writ* ao Supremo Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. [...]. (STF, HC n. 113890, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 28/2/2014).

A primeira alegação defensiva diz respeito à suposta nulidade da prisão em flagrante e apreensão de drogas no interior da residência do paciente, sob a alegação de que o ingresso forçado não foi precedido de prévias e fundadas razões.

Sobre a busca em domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

> 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

> casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603.616, Relator(a): Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito - DJe-093, divulg 9/5/2016, public 10/5/2016)

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, *O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente,*

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, **o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, como se deu na hipótese dos autos, poderá ser eventualmente violado o direito à intimidade de terceiros (parentes em geral do suspeito, exemplificativamente), situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.**

Nesse ponto, necessário enfatizar, de outro lado, **modificando-se de certo foco da jurisprudência até o presente consolidada, que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não resta desconhecido que a busca e apreensão domiciliar podem ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.**

Postas tais premissas, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.

Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, **a diligência restaria convalidada desde que se demonstre que: de modo inequívoco o excepcional consentimento do morador restou livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito abordado pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada, justificada na permanência característica do delito de tráfico ilícito de drogas, por exemplo, resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência**

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.

Feitas essas ponderações, constata-se que as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem policial deram subsídios aos agentes quanto à ocorrência de crime permanente. Desse modo, não se pode falar que a abordagem policial careceu de elementos prévios indicativos da ocorrência de crime no interior do imóvel. Não houve arbitrariedade ou qualquer outro vício na abordagem policial, que, à toda evidência, decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.

Nesse sentido:

> PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM *HABEAS CORPUS*. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EM FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO *HABEAS CORPUS* NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE FLS. 240-250.
> 1. O Requerente busca a obtenção de efeitos infringentes. Dessa forma, em razão de ter sido protocolado dentro do prazo recursal, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, com fundamento nos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos.
> 2. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.
> 3. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que o ingresso em domicílio se deu **em situação de flagrante**, porquanto após troca de tiros no local, a polícia foi acionada e, ao chegarem no local, diante da existência de vestígios de sangue, entraram na residência para averiguar a existência de feridos, ocasião em que foram encontradas drogas, arma, munição e balanças de precisão.
> 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso desprovido. Prejudicado o pedido de fls. 240-250. (RCD no HC n. 806.008/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a

O pleito subsidiário diz respeito à aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o *quantum* dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes: AgRg no HC n. 518.533/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019; AgRg no Resp n. 1.808.590/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 4/9/2019; AgRg no AREsp n. 1.281.254/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019; AgRg no HC n. 490.027/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019.

Neste caso, além da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, não foram mencionadas outras circunstâncias fáticas para justificar a exclusão do benefício. Desse modo, mostra-se prudente e proporcional a incidência da minorante em seu patamar mínimo (1/6), de maneira que a pena resultante passa a ser de **4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão**, mais **417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa**, mantidos os demais termos da sentença condenatória, considerando que o *quantum* fixado desautoriza tanto o abrandamento de regime quanto a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos.

Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **não conheço** deste *habeas corpus*. De ofício, **concedo a ordem** para redimensionar a pena, nos termos acima mencionados.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA55290689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 23:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d6a65f-502b-49b9-aab8-1df88cf5664a